

刑法
No155

R7-17

(配点：2)

月 日

月 日

アからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものの個数を1から5までの中から選りなさい。

- ア. 甲と乙が窃盗を共謀したが、実行行為を分担した甲が同共謀に反して財物を強取した後、実行行為を分担しなかった乙に対し、同財物を強取した旨を伝えて同財物を譲り渡した。この場合、乙に強盗罪の共同正犯が成立することはない。
- イ. 甲（22歳）と乙（12歳）が強盗を共謀し、同共謀に基づき乙が財物を強取した。この場合、甲に強盗罪の共同正犯が成立することはない。
- ウ. 甲と乙が窃盗を共謀し、次に乙と丙が同窃盗を共謀して、同共謀に基づき丙が財物を窃取した。この場合、甲に窃盗罪の共同正犯が成立することはない。
- エ. 甲と乙が強盗を共謀し、同共謀に基づき甲がAに包丁を突き付けて脅迫し、乙がAから金品を強取したが、その強盗の機会に、甲が過失によりAに傷害を負わせた。この場合、乙に強盗致傷罪の共同正犯が成立することはない。
- オ. 甲と乙が窃盗を共謀し、同共謀に基づき甲が実行行為を行ったが、乙は同実行行為の日時・場所・方法を詳細に認識していなかった。この場合、乙に窃盗罪の共同正犯が成立することはない。

1. 1個 2. 2個 3. 3個 4. 4個 5. 5個

No155

R7-17

共同正犯の成否

正解

4

正答率

61%

ア 正しい

従来から判例は、抽象的事実の錯誤について法定的符合説を採用しており、認識した事実と発生した事実の構成要件が実質的に重なり合う限度で軽い罪が成立するとしている。本記述において、乙が認識している事実は窃盗の共謀であるところ、実際に発生した事実は強盗である。そうすると、強盗の意思がない乙には刑法 38 条 2 項により強盗罪の共同正犯は成立せず、窃盗罪と強盗罪の重なり合う限度である窃盗罪の共同正犯が成立するということになる。

イ 誤っている

最決平 13.10.25 は、12 歳 10 か月の長男には是非弁別の能力があり、母親の指示・命令は長男の意思を抑圧するに足りるものではなく、長男は自らの意思によって強盗の実行を決意した上、臨機応変に対処して強盗を完遂し、奪ってきた金品はすべて母親が領得したという事情の下で、母親と長男との間に共同正犯の成立を認めている。判例の結論に賛成する学説は、成人と刑事未成年との間に共同正犯が成立し得る理由として、共同正犯の成立には、有責性の要件は本来、行為者各個人に向けられた非難可能性の問題であるから、その判断は個別的に行われるべきであり、共犯者間で責任が連帯する必要はないということを挙げている。

ウ 誤っている

最大判昭 33.5.28 (百選 175 事件) は、「数人の共謀共同正犯が成立するためには、その数人が同一場所に会し、かつその数人間に一個の共謀の成立することを必要とするものでなく、同一の犯罪について、甲と乙が共謀し、次で乙と丙が共謀するというようにして、数人の間に順次共謀が行われた場合は、これらの者のすべての間に当該犯行の共謀が行われたと解する」としている。したがって、順次共謀の形式でも、共謀共同正犯は成立し得る。

エ 誤っている

最判昭 26.3.27 は、「傷害致死行為は強盗の機会において為されたものといわなければならないのであつて、強盗について共謀した共犯者等はその一人が強盗の機会において為した行為については他の共犯者も責任を負う」として、強盗致死罪の成立を認めている。したがって、甲及び乙が A に対する強盗を共謀したが、その強盗の機会に、甲が過失により A に傷害を負わせた場合、甲及び乙に強盗致傷罪の共同正犯が成立する。

オ 誤っている

共謀における意思連絡の内容は、犯行の本質的部分について共謀者間に了解があることを必要とするが、犯罪の日時、場所、方法などを詳細に認識している必要はない。したがって、乙に窃盗罪の共同正犯が成立する可能性はある。

以上により、誤っている記述はイ、ウ、エ、オの 4 個であり、したがって、正解は肢 4 となる。